

1500744-50.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... quando interrogado em juízo, negou a prática do tráfico.

A negativa, no entanto, soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida, porque em contradição com a lógica e com a prova produzida.

Veja-se que, em solo policial, houve confissão quanto à prática do tráfico (fls. 07).

A confissão extrajudicial é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500744-50.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500744-50.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2181540/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 18886428 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 3520/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2181540 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 3520/21/050 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREY GABRIEL DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

ANDREY GABRIEL DE OLIVEIRA foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 05 de julho de 2021, por volta das 20h21, na Alameda Babilônia, 9-25, bairro Santa Edwiges, nesta cidade, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 118,52 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 95), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 96/97.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 10 de agosto de 2021 (fls. 99/102). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 144 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 149/153).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 158/160, alegando que: 1)- o réu negou a prática do crime; 2)- cada policial relatou uma versão; 3)- o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 13 e pelo laudo pericial de fls. 128/132 (três porções de maconha com peso de 4,38 gramas e cinquenta porções de maconha com peso de 114,14 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Interrogado na polícia, ele declarou que estava no local da abordagem vendendo drogas. Vendia cada porção de maconha por cinco reais. Na ocasião, estava com apenas três porções desse entorpecente. Indicou aos policiais onde estavam as demais. Era a primeira vez que estava traficando. Buscava sustentar seu filho recém nascido. Trabalhava como ajudante de pintor com seu pai (fls. 07).

Em juízo, a testemunha Luis Cláudio Andreotti Júnior, policial militar, afirmou ter sido acionado pelo COPOM para averiguar notícia de tráfico, segundo a qual Andrey cometia o crime na rua Babilônia. A informação dava conta das características e vestes do acusado. Dirigiu-se ao local e o surpreendeu. Ele tinha as mesmas características e nome informados na notícia. Com a chegada da polícia, o réu tentou se evadir, mas foi detido. Em revista pessoal, foram encontradas três porções de maconha e sessenta reais em espécie. As porções estavam no interior de saquinhos "zips" transparentes. Indagado, o réu confessou a prática do tráfico e indicou o local onde havia mais entorpecente. No lugar por ele mencionado, um terreno baldio situado a cerca de trinta metros de distância, foram localizadas mais quarenta e oito porções de maconha, embaladas do mesmo modo, ou seja, em saquinhos "zips". O réu disse que vendia o entorpecente por cinco reais cada porção. Foram achadas ainda duas porções ainda sem fracionar. O acusado afirmou que o dinheiro apreendido provinha do tráfico. Não o conhecia. Estava a um mês no policiamento naquele bairro. Não se lembra se o réu informou há quanto tempo praticava o comércio de drogas. As porções encontradas no terreno estavam embaladas de forma idêntica às aquelas localizadas com o réu. Somente foram apreendidas porções de maconha.

A testemunha Diego Vinicius Cordeiro, também policial militar, relatou ter sido "irradiada" pelo COPOM uma denúncia de prática de tráfico. Foram passadas as características de vestimentas do traficante e do local onde ele exercia o comércio proibido. Foi até o lugar mencionado. O réu, ao ver a viatura, tentou se evadir, mas foi de pronto abordado. Com ele, foram localizadas três porções de maconha e sessenta reais em dinheiro. Indagado, o réu confessou a prática do tráfico e informou que guardava mais porções de entorpecente em um outro terreno, situado a cerca de cinquenta metros do local da abordagem. No ponto indicado, foram encontradas mais quarenta e oito porções de maconha embaladas para venda. O acusado afirmou que vendia cada uma delas por cinco reais. Ainda havia no terreno mais duas porções brutas para fracionamento. As porções - tanto as que estavam em poder do réu como aquelas que estavam guardadas - estavam embaladas em pacotes tipo "zip", que abrem e fecham. As embalagens eram iguais. Não conhecia o acusado dos meios policiais. Não havia outro tipo de droga, somente maconha.

A testemunha Rosimeire Delchiaro Bispo informou que a família do réu era sua vizinha. Não sabe sobre o fato. Tomou conhecimento do ocorrido através da avó do acusado. Nunca soube que ele tinha vínculo com drogas. Soube que o réu trabalhou fazendo bicos de pintura com o pai. Na época, não residia mais perto da família deles. A avó do réu, com quem ele morava, era pessoa estruturada. Já o pai e a mãe

estavam presos em razão de drogas. Ele trabalhava com o marido da avó, entregando encomendas e fazendo gesso. O pai do acusado já saiu da cadeia. Andrey não trabalha mais com o pai. Sabe, porém, que ele trabalha.

A testemunha Pedrina Dalpino afirmou conhecer o réu desde que ele tinha três anos. Conhece a família dele. Nada sabe sobre o fato. Na época, o acusado trabalhava fazendo bicos com a avó e com o tio. Ele trabalha com gesso. Trata-se de pessoa que sempre trabalhava. A avó e a mãe são as estruturas do acusado. Não sabe se o pai ele tem vícios, pois faz tempo que não o vê. Soube que o genitor tocou fogo na casa, situada ao lado da sua (da testemunha). Andrey sofria quando vivia com o pai. Atualmente, o réu vive vida tranquila com a avó e trabalha.

Interrogado em juízo, o acusado afirmou que estava com três porções de maconha. O restante das drogas não era de sua propriedade e estava a cinco quarteirões do local da abordagem. Portava somente as três porções e sessenta e cinco reais. Não sabe como os policiais encontraram o resto do entorpecente. É usuário de maconha e está tentando fazer tratamento no CAPS. Estava em frente a uma pizzaria, esperando uma pizza.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

É certo que o réu, quando interrogado em juízo, negou a prática do tráfico.

A negativa, no entanto, soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida, porque em contradição com a lógica e com a prova produzida.

Veja-se que, em solo policial, houve confissão quanto à prática do tráfico (fls. 07).

A confissão extrajudicial é relevante elemento de convicção.

Nesse sentido:

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil." (TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

Na fase judicial, a prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, que flagraram o réu na posse de três porções de maconha e de dinheiro, bem como encontraram, justamente em lugar por ele indicado, outras quarenta e oito porções embaladas de forma idêntica àquelas três (saquinhos "zip") e outras duas ainda a serem fracionadas.

Não há razão para colocar em dúvida a palavra dos policiais.

Afinal, por qual razão dois servidores públicos iriam à polícia e depois viriam em juízo para, na presença do magistrado e das partes, afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoa que sequer conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e até criminalmente pela falsa acusação?

Ademais, as afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Portanto, o fato descrito na denúncia, objetivamente considerado, e respectiva autoria estão bem demonstrados.

Por outro lado, inexiste dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico. É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso, após notícia anônima, o agente, detentor das mesmas características informadas pelo denunciante, foi surpreendido na posse de dinheiro e também de porções de maconha cuja quantidade era mais do que suficiente para caracterização de situação de comércio espúrio.

Em tais circunstâncias, não é possível cogitar de mero porte para consumo, na medida em que usuário nenhum mantém, em plena via pública, tamanha quantidade de entorpecente para simples deleite.

Poder-se-ia até cogitar de desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas caso a droga tivesse sido apreendida no interior de residência.

Mas, aqui, insista-se, o caso é diverso, ou seja, cuidou-se de situação em que o agente foi surpreendido em via pública, no período noturno, na posse direta de três porções de maconha e guardando outras quarenta e oito embaladas de forma idêntica, num terreno.

Vale dizer que o fato espelha nítida condição de traficante, que mantém pequena parte de entorpecente consigo, para atender os usuários de forma mais rápida, e que, ao mesmo tempo, oculta o restante da droga, para buscá-la conforme a procura de usuários e sem levantar maiores suspeitas.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a guarde e a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Em suma, deve o réu ser condenado no s termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu não tem antecedentes criminais (fls. 37/38).

Diante disso, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11343/2006.

Destaque-se que a quantidade de droga apreendida, mormente se se considerar que a apreensão recaiu sobre maconha, não era das mais elevadas, não sendo possível inferir, a partir daí, que o réu se dedicava a atividade criminosa.

Nenhum outro elemento de convicção indica tratar-se de agente integrante de organização criminosa ou dedicado a atividade criminosa.

Cabível, pois, a incidência da causa de diminuição de pena.

Afigura-se justo deferir a redução no grau máximo de dois terços, tendo em vista que as quantidades de droga e de dinheiro apreendidas não foram das mais elevadas.

Destarte, a pena resulta em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia

27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, pequenas quantidades de droga e dinheiro), fixa-se o regime inicial aberto.

Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, e, ainda, o fato de as quantidades de droga e de dinheiro não serem das mais elevadas, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Andrey Gabriel de Oliveira como incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Oportunamente, anote-se as condenações no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, §

1º, da Lei n. 11.343/2006.
P.R.I.
Bauru, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA